

次の【記述】は、控訴審の権限に関して判断を示した最高裁判所決定の要旨である。①から⑦までの()内に後記aからiまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【記述】

第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は、牽連犯ないし包括一罪として起訴された事実の一部なのであるから、右第一審判決に対する控訴提起の効力は、それが被告人からだけの控訴であつても、公訴事実の全部に及び、右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移審係属すると解すべきである。そうとすれば、控訴裁判所は右起訴事実の全部の範囲にわたつて①を加えることが可能であるとみられないでもない。しかしながら、控訴審が第一審判決について①をやるにあたり、いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては、さらに慎重な検討を要するところである。いうまでもなく、現行刑事訴訟法においては、いわゆる②主義が基本原則とされ、③主義はその補充的、後見的なものとしてされているのである。②主義の現われとして、現行法は④制度をとり、検察官が公訴を提起するには、⑤を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならないが、⑤は④を明示してこれを記載しなければならないこととし、この④につき、当事者の攻撃防御をなさしめるものとしている。(中略)このように、審判の対象設定を原則として②の手に委ね、被告人に対する不意打を防止し、

②の公正な訴訟活動を期待した第一審の訴訟構造の上に立つて、刑事訴訟法はさらに控訴審の性格を原則として⑥審たるべきものとしている。すなわち、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前記のような②の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに⑥的な審査を加えるべきもののなのである。そして、その⑥審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であつて、①はあくまで補充的なものとして理解されなければならない。けだし、前記の第一審における②主義と③主義との関係は、控訴審においても同様に考えられるべきだからである。

これを本件についてみるに、本件公訴事実中第一審判決において有罪とされた部分と無罪とされた部分とは牽連犯ないし包括一罪を構成するものであるにしても、その各部分は、それぞれ1個の犯罪構成要件を充足し得るものであり、④としても独立し得たもののなのである。そして、右のうち無罪とされた部分については、被告人から不服を申し立てる利益がなく、検察官からの控訴申立てもないのであるから、当事者間においては攻防の対象からはずされたものとみることができる。このような部分について、それが理論上は控訴審に移審係属しているからといって、⑥審たる控訴審が①を加え有罪の自判をすることは、被告人控訴だけの場合、刑事訴訟法第402条により第一審判決の刑より重い刑を言い渡されないことが被告人に保障されているとはいつても、被告人に対し不意打を与えることであるから、前記のような現行刑事訴訟の基本構造、ことに現行控訴審の性格にかんがみるときは、⑦として許される限度をこえたものであつて、違法なものといわなければならない。

【語句群】

- a. 職権調査 b. 当事者の申立てに基づく調査 c. 当事者 d. 職権 e. 訴因
f. 公訴事実 g. 事実 h. 事後 i. 職権の発動

1. ①b④e 2. ①a⑦i 3. ②d⑤f 4. ②c⑥g 5. ③c⑥h

I. まず、【記述】の①から⑦までに入る語句を明らかにする。

本問の【記述】は、最大決昭46.3.24（新島ミサイル事件）の判旨である。

完成全文

第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は、牽連犯ないし包括一罪として起訴された事実の一部なのであるから、右第一審判決に対する控訴提起の効力は、それが被告人からだけの控訴であつても、公訴事実の全部に及び、右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移審係属すると解すべきである。そうとすれば、控訴裁判所は右起訴事実の全部の範囲にわたつて（①a.職権調査）を加えることが可能であると考えられないでもない。しかしながら、控訴審が第一審判決について（①a.職権調査）をするにあたり、いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては、さらに慎重な検討を要するところである。いうまでもなく、現行刑法において、いわゆる（②c.当事者）主義が基本原則とされ、（③d.職権）主義はその補充的、後見的なものとされているのである。（②c.当事者）主義の現われとして、現行法は（④e.訴因）制度をとり、検察官が公訴を提起するには、（⑤f.公訴事実）を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならないが、（⑤f.公訴事実）は（④e.訴因）を明示してこれを記載しなければならないこととし、この（④e.訴因）につき、当事者の攻撃防御をなさしめるものとしている。

（中略）このように、審判の対象設定を原則として（②c.当事者）の手に委ね、被告人に対する不意打を防止し、（②c.当事者）の公正な訴訟活動を期待した第一審の訴訟構造の上に立つて、刑事訴訟法はさらに控訴審の性格を原則として（⑥h.事後）審たるべきものとしている。すなわち、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前記のような（②c.当事者）の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに（⑥h.事後）的な審査を加えるべきものである。そして、その（⑥h.事後）審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であつて、

（①a.職権調査）はあくまで補充的なものとして理解されなければならない。けだし、前記の第一審における（②c.当事者）主義と（③d.職権）主義との関係は、控訴審においても同様に考えられるべきだからである。

これを本件についてみるに、本件公訴事実中第一審判決において有罪とされた部分と無罪とされた部分とは牽連犯ないし包括一罪を構成するものであるにしても、その各部分は、それぞれ1個の犯罪構成要件を充足し得るものであり、（④e.訴因）としても独立し得たものである。そして、右のうち無罪とされた部分については、被告人から不服を申し立てる利益がなく、検察官からの控訴申立てもないのであるから、当事者間においては攻防の対象からはずされたものとみることができる。このような部分について、それが理論上は控訴審に移審係属しているからといって、（⑥h.事後）審たる控訴審が（①a.職権調査）を加え有罪の自判をすることは、被告人控訴だけの場合、刑事訴訟法第402条により第一審判決の刑より重い刑を言い渡されることが被告人に保障されているとはいつても、被告人に対し不意打を与えることであるから、前記のような現行刑事訴訟の基本構造、ことに現行控訴審の性格にかんがみるときは、（⑦i.職権の発動）として許される限度をこえたものであつて、違法なものといわなければならない。

①から⑦までには順に、①＝a.職権調査、②＝c.当事者、③＝d.職権、④＝e.訴因、⑤＝f.公訴事実、⑥＝h.事後、⑦＝i.職権の発動と入り、正しい組合せは「①a⑦i」であり、したがって、正解は肢2となる。

II. 次に、①から⑦までに入る語句の導き方を検討する。

①について

第1に、要旨中「起訴事実の全部の範囲にわたって(①)を加える」という部分から、調査ないし審理の語句が入ると推測できる。第2に、「(①)をするにあたり、いかなる限度においてその職権を行使すべきか」という部分から、職権の発動が可能なことを前提に、その限界が問われている。よって、①には「a.職権調査」が入る。

②および③について

要旨中「現行刑法において、いわゆる(②)主義が基本原則とされ、(③)はその補充的、後見的なものとされている」という部分から、現行刑事訴訟法の構造における基本原則とその例外との関係が問われている。現行法の訴訟構造は当事者主義を基本とし、他方で、当事者の訴訟追行を円滑に進めるため、ないし被告人側の防御能力不足を補うために、当事者主義と対立しない範囲で、職権主義が採用されている(294条、298条2項等参照)。このように、現行刑事訴訟法においては、当事者主義が基本原則とされ、職権主義は当事者主義を補充するものである。よって、②には「c.当事者」が入り、③には「d.職権」が入る。

④および⑤について

要旨中「現行法は(④)制度を取り、検察官が公訴を提起するには、(⑤)を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならない、(⑤)は(④)を明示してこれを記載しなければならない」という部分から、256条1項、2項2号、3項前段が参考になる。256条3項前段は、「公訴事実、訴因を明示してこれを記載しなければならない」としている。よって、④には「e.訴因」が入り、⑤には「f.公訴事実」が入る。

⑥について

要旨中「控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前期のような(②[当事者])の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに(⑥)的な審査を加えるべきもの」という部分から、控訴審の審理形態が問われている。刑事訴訟法においては、控訴審は、事件そのものではなく、原判決の当否を審査する形態である事後審が採用されている。よって、⑥には「h.事後」が入る。

⑦について

要旨中「控訴審が(①[職権調査])を加え有罪の自判をすることは、(中略)(⑦)として許される限度をこえたもの」という部分から、職権の語句が入ると推測できる。そして、①から⑦までの()内にはそれぞれ異なる語句が入るものとされているので、⑦には、既に用いた「a.職権調査」及び「d.職権」は入らない。よって、⑦には、残る「職権」の語を用いた「i.職権の発動」が入る。

